

1502354-77.2019.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502354-77.2019.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502354-77.2019.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

RONI FABRICIO CAYRES e JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Carlos Ângelo Mation nº 1, Viela 38, Jardim Tamoio, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fim de tráfico, as substâncias descritas na denúncia, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento rotineiro no local, avistaram os acusados que, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, mas acabaram detidos. Realizada a revista, em poder de Roni foram apreendidos um rádio comunicador e a quantia de R\$ 161,00 e, com Jhonata uma sacola contendo 37 porções de maconha, 14 porções de "crack", 68 porções de cocaína e 20 de lança-perfume, além da importância de R\$ 80,00, em dinheiro.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias das apreensões, foram presos em flagrante.

Notificados, os réus apresentaram defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, após manifestação do Ministério Público, foi oferecido Acordo de Não Persecução Penal aos acusados, que aceitaram, homologando-se o acordo.

Posteriormente, foi revogado o acordo em relação ao corréu Roni, ante seu descumprimento, e designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que ouviram-se duas testemunhas e esse réu foi interrogado.

Após a audiência, o benefício também foi revogado em relação a Jhonata e, ante a concordância das partes com a utilização da prova emprestada, designada audiência para seu interrogatório.

Encerrada a instrução, em debates, a Promotora de Justiça analisou a prova e pediu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa, em preliminar, arguiu a ilicitude da prisão dos réus, fez que realizada por guardas municipais sem que houvesse situação de flagrância, em patente violação ao artigo 144 da Constituição Federal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Em caso de entendimento diverso, requereu o que segue: desclassificação do delito, com relação ao corréu Roni, para aquele tipificado no artigo 37 da Lei nº 11.343/06; fixação da pena-base no patamar legal; reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; imposição de regime inicial aberto; substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto. RELATADO.

DECIDO.

Observe-se, desde logo, que as partes concordaram com a prova emprestada relativamente a Jhonata.

A preliminar suscitada não merece guarida.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem dos réus realizada pelos guardas municipais, vez que quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de

nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Importante observar, outrossim, que, no caso dos autos, não foram extrapoladas as funções típicas da Guarda Municipal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a busca e apreensão feita a partir de fundada suspeita de flagrância, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, é permitida à Guarda Civil Municipal, não havendo abuso de função.

Nesse sentido, "1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC nº 667.413/SP, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021).

E mais, "(...) Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundada suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes" (STJ, HC 742.941/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Jesuino Rissato (Desembargador convocado), DJe 16/08/2022).

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastada a preliminar, no mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia deve ser julgada procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 24/27 e 138/141), provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Incontroversa a prova de autoria.

Em Juízo, o réu Roni confessou a imputação, afirmando que exercia a função de "olheiro" e recebia pagamento em dinheiro. Na data dos fatos, conseguiu avisar Jhonata sobre a chegada da viatura. Em seu poder foi apreendido um rádio-comunicador.

Inegável o valor da confissão judicial, que somente perderá seu valor se desmentida

pelas demais provas, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso em tela.

Já o acusado Jhonata negou o cometimento do crime, dizendo que estava no local fazendo uso de tóxico e acabou sendo interceptado. Não conhecia os guardas municipais que efeturaram sua prisão e nada tinha contra eles.

Sucedendo que tal negativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade, observando-se que quando da audiência de Proposta de Acordo de Não Persecução Penal, esse réu confessou.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Luiz Relvy de Sousa Correia e Jonas Botelho Marestoni, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas, do dinheiro e demais objetos em poder dos réus. Esclareceram, ainda, que em poder de Roni foi apreendido o rádio-comunicador e certa quantia em dinheiro, vez que ele atuava como "olheiro", enquanto em poder de Jhonata foi apreendida a droga. Os réus, informalmente, confessaram a traficância.

E as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação.

Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados que não conheciam, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Inviável a pretendida desclassificação para o artigo 37 da Lei nº 11.343/06, como requerido pela defesa de Roni, apesar da divergência sobre o tema.

Realmente, no caso em tela as circunstâncias delitivas comprovadas nos autos, além da considerável quantidade e variedade de drogas e do dinheiro apreendidos este último apreendido em poder do acusado, demonstram que ele praticava o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Observe-se, outrossim, que o fato do corréu Jhonata ter se declarado usuário de drogas não tem o condão de afastar a prática de comércio ilícito de entorpecentes, sendo plenamente possível e comum a coexistência das duas condições.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR os réus RONI FABRICIO CAYRES e JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base, para ambos os réus, no patamar legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que as circunstâncias judiciais os favorecem.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes com relação a Jhonata.

As atenuantes da confissão e da menoridade relativamente a Roni, não podem ser reconhecidas, ante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Reduzo a pena de 2/3 (dois terços), somando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) diárias, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Excepcionalmente, por serem primários, poderão cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto, de acordo com a jurisprudência mais recente dos nossos tribunais, observando que poderá apelar em liberdade, porquanto respondeu solto ao processo.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por um ano, devendo no mesmo prazo frequentarem programas específicos relacionados ao uso de drogas existentes na Comarca.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Assim, ficam os réus RONI FABRÍCIO CAYRES e JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, condenados à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) diárias, como incursos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a corporal nos termos acima propostos.

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 29 de novembro de 2022.

JANE RUTE NALINI ANDERSON
Juíza de Direito